

1501452-32.2019.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501452-32.2019.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501452-32.2019.8.26.0510 - 2019/000536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

BRUNO LOPES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

BRUNO LOPES DOS SANTOS, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 09 de abril de 2019, por volta das 22h30min, na Rua 12 MP, nº 376, Mãe Preta, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito 20 (vinte) invólucros contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol, totalizando peso líquido aproximado de 58,1 gramas, e 01 (um) invólucro contendo a mesma substância entorpecente, revelando peso líquido aproximado de 98,1 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 48/49, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 55/56).

Regularmente notificado (fls. 70), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado (fls. 72/77), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 13 de novembro de 2019 (fls. 85/88).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa (fls. 145), seguindo-se o interrogatório do acusado (fls. 145).

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime prisional inicial aberto (fls. 145).

Já os ilustres Defensores, preliminarmente, reiterando o que exposto em sede de defesa preliminar, sustentaram ilícita a apreensão do entorpecente, porque em violação a domicílio, a determinar a absolvição nos termos do disposto no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. De outra parte, quanto ao mérito, em caso de condenação, requereram a fixação da pena base no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, no patamar máximo, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão, além da restituição do valor em dinheiro apreendido (fls. 146/159 e documentos de fls. 160/161).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito o material entorpecente descrito na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 48/49, com resultado positivo para tetrahidrocannabinol, responsável pelos efeitos estupefacientes da maconha, e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10.

Sustenta-se que estaria comprometida a apreensão do entorpecente, prejudicando a materialidade do delito, em razão da ilícita abordagem inicial, porque fundada em denúncia anônima, como também em razão da violação do domicílio.

Entretanto, respeitado o entendimento exposto pelos combativos Defensores, a questão já foi tratada por ocasião do saneamento do feito (fls. 85/88), reiterando-se que, após o recebimento da denúncia anônima mencionada, Policiais Militares se dirigiram à residência do Acusado e lá, recebidos pelo genitor dele – que autorizou o ingresso no imóvel –, foram encontrados: substância entorpecente, importância em dinheiro, balança de precisão, expressiva quantidade de plásticos utilizados para o acondicionamento da droga e um caderno com anotações, aparentemente relacionadas ao comércio ilícito.

E a denúncia anônima não maculou as diligências que se seguiram. Entendimento recente do Egrégio Supremo Tribunal Federal aponta ser possível a comunicação anônima. Sobre isto: "Agravamento regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Deflagração da persecução penal pela chamada "denúncia anônima". Possibilidade. 5. Ulteriores diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados. 6. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais do artigo 5º, incisos LIV e LVI. 7. Necessidade de reexame fático-probatório que encontra óbice na Súmula 279/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1069179 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

E a autoria atribuída ao acusado é certa.

Ouvido em Juízo, o acusado admitiu que estaria armazenando entorpecente para o traficante de quem adquiria a substância ilícita, já que era usuário. Não quis identificar/qualificar a pessoa para quem estava realizando a guarda, assim por receio de represálias contra ele ou contra a própria família. Acrescentou que o caderno de anotações apreendido referia-se a gastos mensais realizados, inclusive no cartão de crédito de seu genitor, não estando relacionado ao entorpecente apreendido. Ademais, cuidou em informar que o valor em dinheiro igualmente apreendido advinha de economias realizadas pela família (fls. 145).

A versão deduzida pelo acusado foi confirmada pela prova produzida.

De fato, os Policiais ouvidos, Josinei e Angel, esclareceram que o setor de inteligência da DISE na ocasião recebeu informações de pessoas residentes do bairro Mãe Preta, de que o acusado estaria armazenando entorpecente, em sua moradia, para realizar a comercialização. A Polícia Civil já havia recebido informações contendo

o nome e o endereço da moradia do acusado. Policiais Militares estiveram na residência do acusado e foram recebidos pelo genitor dele, que foi bastante cordial com a equipe e autorizou o ingresso no imóvel. No interior do quarto do acusado foi localizada a substância entorpecente, além de petrechos - balança de precisão, embalagem para acondicionamento do entorpecente, além de caderno contendo anotações, não tendo sido o acusado localizado posteriormente (fls. 145).

Acresça-se que, como se tem reiteradamente sustentado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais envolvidos na diligência.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Osmar, genitor do acusado, ouvido em juízo, confirmou que na ocasião dos fatos Policiais Militares ingressaram em sua moradia, antes mesmo de abrir o cadeado do portão -- ouvido contemporaneamente aos fatos afirmou que autorizou a entrada no imóvel --, não sabendo informar como tinham conhecimento da localização do quarto do acusado, onde, de fato, foi apreendida substância entorpecente. Acrescentou que posteriormente conversou com o acusado, tendo ele confidenciado que o material apreendido -- maconha, além de uma balança de precisão bem como embalagens plásticas -- estava sendo armazenado para terceira pessoa, que não quis identificar. Relatou que o caderno apreendido, na moradia, continha anotações referentes a pagamentos que o filho realizava, em razão de usar o seu cartão de crédito (fls. 145).

Deste modo, os elementos probatórios produzidos permitem seguro juízo de convicção sobre o armazenamento do entorpecente, bem como sobre sua destinação mercantil, não apenas em função da quantidade apreendida, como também em razão das circunstâncias relacionadas à apreensão.

Deixa-se de impor a pena de perdimento da quantia em dinheiro apreendida na moradia, porque não há, por aqui, indicação segura de que decorrente da atividade ilícita, devendo ser oportunamente restituída.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, sendo o acusado primário e não se evidenciando que estivesse dedicado ao tráfico ilícito de entorpecente, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da confissão espontânea, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

Entretanto, deve pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no

artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não havendo indicação suficiente, por ocasião dos fatos, de que estivesse já dedicado à atividade criminosa, de tal modo que deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observa os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a

tese segundo a qual o trafico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado BRUNO LOPES DOS SANTOS à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se a restituição dos valores apreendidos e o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA